

1500805-78.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Resistência

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... de pena pela prática do delito de tráfico de drogas praticado na Cidade de Capela do Alto. Disse ainda que já foi condenado anteriormente por agressão e, na infância, pela prática do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Sobre os fatos, alegou ser apenas usuário de drogas. Reside no Bairro Cercadinho em Capela do Alto. Adquiriu as drogas de uma pessoa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500805-78.2022.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500805-78.2022.8.26.0624

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Resistência

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3057964/2022 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE JOILSON LEITE DA SILVA

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

JOSÉ JOILSON LEITE DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 03 de maio de 2022, por volta das 16h50, na Rua Lourenço Alves Carriel, nº 30, Distrito do Porto, na Cidade de Capela do Alto, nesta Comarca de Tatuí, nas imediações de praça pública e em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 02 (duas) porções de cocaína, com peso bruto de 3,01 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

JOSÉ JOILSON LEITE DA SILVA também foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 329, § 1º, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, como narra a denúncia, nas

mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em ocasião de calamidade pública, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, não se executando o ato em razão da resistência. O réu foi notificado (fl. 56) e apresentou defesa prévia (fls. 63/64). A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022 (fls. 76/77) e o réu foi citado (fl. 88).

Durante a audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu. Encerrada a instrução processual, passou-se aos debates (fls. 96/100).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de JOSÉ JOILSON LEITE DA SILVA, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, em concurso material de delitos (Artigo 69 do Código Penal), transgrediu os preceitos primários das normas penais incriminadoras inseridas no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06; e artigo 329, § 1º, do Código Penal; todos com incidência da circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, a exordial acusatória merece parcial procedência. Isso porque, os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados quanto ao delito de resistência qualificada. Por outro lado, quanto à imputação relativa ao delito de tráfico de drogas, verifico ser caso de desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 04/05, auto de exibição e apreensão de fl. 08, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09/10, laudo de lesão corporal indireto de fls. 12/13, laudo definitivo de entorpecente de fls. 15/17 e pela prova oral colhida. De igual modo, a autoria é incontestada.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise da prova colhida em audiência. Durante a instrução, a testemunha DIEGO TELES CYRINEU, policial militar, informou que na data dos fatos, na companhia do Soldado Leones, realizava patrulhamento pelo Bairro Distrito do Porto. Várias crianças brincavam nas proximidades da Praça Central e uma delas foi até a viatura e relatou que o réu havia deixado três pinos de entorpecentes perto de uma árvore e estava sentado no local. Efetuaram a abordagem do acusado e, durante procedimento de revista pessoal, nada ilícito foi com ele apreendido. No entanto, o parceiro do depoente foi até o local indicado pela criança e encontrou os entorpecentes. Indagado, o réu confessou ter dispensado as drogas após avistar a viatura policial. José Joilson ainda informou ter adquirido as drogas de um cigano conhecido pela alcunha "D" (sic), bem como entregaria as porções para outra pessoa. Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia, o réu empurrou o depoente de forma agressiva fazendo com que caísse no chão e sofresse torção no tornozelo e no joelho, não conseguindo mais ficar em pé. O parceiro do depoente tentou impedir a fuga do acusado, mas não conseguiu. Por conta da lesão sofrida permaneceu sete dias afastado de suas funções. Por fim, disse conhecer o acusado pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas quando ainda era menor e pela prática do delito de furto.

O policial militar FABRICIO LEONES LEME ratificou o depoimento ofertado por Diego Teles Cyrineu.

Por sua vez, o réu JOSÉ JOILSON LEITE DA SILVA contou possuir vinte e quatro anos de idade e atualmente está preso para cumprimento de pena pela prática do delito de tráfico de drogas praticado na Cidade de Capela do Alto. Disse ainda que já foi condenado anteriormente por agressão e, na infância, pela prática do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Sobre os fatos, alegou ser apenas usuário de drogas. Reside no Bairro Cercadinho em Capela do Alto. Adquiriu as drogas de uma pessoa conhecida por "cigano" (sic) e pagou por cada porção a

quantia de vinte reais. Resistiu à ação policial para não ser preso. Apenas empurrou o policial e fugiu.

Os depoimentos e o interrogatório foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. No tocante ao delito de tráfico de drogas atribuído ao réu na denúncia, observa-se das provas amealhadas que não foi presenciado qualquer ato de venda das substâncias ilícitas, sendo a ação policial apenas oriunda de informação recebida por uma criança dando conta de que José Joilson havia dispensado as porções de drogas no local.

Não se olvida que, tendo em vista que o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, basta tão somente que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no preceito primário que, no caso concreto, foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante disso, denota-se duas hipóteses: a bem da verdade, a droga encontrada na posse do réu poderia ser destinada à venda, como também para o consumo próprio. Havendo dúvida insuperável, mormente quando não amparado por elementos hábeis a indicar a prática do tráfico, a solução adequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Além do mais, a quantidade de droga encontrada, por si só, não seria eficaz para sustentar uma condenação com base no artigo 33 da Lei de Drogas, merecendo prestígio a assertiva exposta pelo réu no sentido de que os tóxicos seriam destinados ao seu consumo.

Sequer houve a apreensão de numerário com o acusado para justificar possível venda de drogas no local. E mais, durante a abordagem, além das drogas, foi encontrado um micro tubo vazio igual àqueles que armazenavam as duas porções de cocaína apreendidas, reforçando ainda mais a desclassificação.

Portanto, diante da latente precariedade das provas a ensejar uma conclusão voltada ao tráfico de entorpecente, que, repita-se, exige elementos probatórios robustos, concluo que a droga apreendida com o denunciado seria utilizada para mero deleite próprio.

Diante disto, tais dados são suficientes para conferirem incerteza ao pleito inaugural formulado pelo Ministério Público. Em outros termos, permite entrever que a condição de usuário sobrepõe-se à de traficante, devendo aquela prevalecer. Por consequência, vedada está a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, mister é a desclassificação da conduta imputada ao réu para a tipificação contida no art. 28, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal.

Em relação do delito de resistência qualificada, verifico que estão presentes os elementos subjetivos e objetivos para a sua caracterização.

De fato, para a incidência do tipo penal em apreço, deve o agente agir imbuído da intenção de impedir ou obstruir a execução de ato legal, cuja ação deve ser realizada mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe preste auxílio. E este é o caso dos autos.

Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia de Polícia, o acusado ofertou resistência à ação policial, utilizando-se para tanto de violência em face do agente público, empurrando-o e fazendo com que caísse ao chão e se lesionasse, oportunidade na qual empregou fuga e não foi capturado.

Com isso, evidente que a investida do acusado em face do servidor acabou por frustrar a execução do ato legal, acarretando o exaurimento do delito e a incidência da qualificadora prevista no § 1º do artigo 329 do Código Penal.

Anoto que o réu confessou em audiência que empurrou o agente público para não ser preso e fugiu.

Não fosse isso, as palavras dos policiais militares são dotadas de verossimilhança e amparadas pelo contexto fático delineado, porquanto não foi demonstrada qualquer

eiva em seus depoimentos, de forma a explicitar a intenção deles em mentir em juízo e incriminar inocente.

Deve-se indicar ainda ser iterativa a jurisprudência dos nossos tribunais no sentido de que os agentes de segurança, mormente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional. Os depoimentos dos agentes que atuaram na diligência merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral. Somente podem ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição. Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, as suas palavras servem como prova suficiente para informar o convencimento do julgador.

Sendo assim, a prova produzida foi clara e suficiente para o deslinde da ação delituosa, não havendo se falar em ausência ou insuficiência de provas. Destarte, provadas a autoria e materialidade do delito de resistência qualificada, a procedência da denúncia neste aspecto é medida de rigor.

DOSIMETRIA DA PENA.

Do delito de posse de drogas para uso próprio (Artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06).

Tendo por base as diretrizes insculpidas no artigo 59 do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando ainda que o réu ostenta condenações anteriores que são aptas a gerar reincidência (Processos nº 1500406-48.2021.8.26.0571, nº 1500917-18.2020.8.26.0624 e nº 0005010-69.2018.8.26.0624 - certidão de fls. 51/55), bem como houve a confissão espontânea do crime (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP e Súmula nº 545 do STJ), verifico que o mais adequado ao caso concreto é a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade no prazo de 02 (dois) meses.

Do delito de resistência qualificada (Artigo 329, § 1º, do Código Penal).

Na primeira fase, observo que o réu é portador de três condenações por fatos anteriores, transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e as demais a agravante de reincidência sem que se incorra em bis in idem, conforme jurisprudência do C. STJ ("É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018).

Desse modo, considerarei a condenação definitiva operada nos autos do Processo nº 0005010-69.2018.8.26.0624 (certidão de fl. 51/55, notadamente à fl. 52) como maus antecedentes.

As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. A anotação referente ao Processo nº 1500948-32.2022.8.26.0571, constante na certidão acima apontada, não pode servir para agravar a pena-base do acusado, em atenção ao teor do verbete sumular nº 444, do STJ, segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Desta feita, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, a saber: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente, conforme visto acima (Processos nº 1500406-48.2021.8.26.0571 e nº 1500917-18.2020.8.26.0624 - fls. 51/55), incide ao caso a agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Ressalvado o entendimento adotado outrora, adequando-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

"Em relação à agravante prevista no art. 61, I, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se

prevaleceu da pandemia par a prática delitiva." (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

"Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexos com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico." (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexos causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea do agente (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP), a qual deve ser levado em consideração, em atenção à Súmula nº 545 do STJ.

Desta feita, nos termos do artigo 67 do Código Penal, tratando-se de dupla reincidência, deve a agravante prevalecer sobre a atenuante, porém em patamar razoável e proporcional. Para tanto, procedo ao agravamento da pena em mais 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, alcançando o patamar de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda fica estabelecida em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS.

O agente incidiu na prática de dois delitos, mediante mais de uma ação, sendo o caso de reconhecimento do concurso material de delitos previsto no artigo 69 do Código Penal. E, para tanto, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, ficando estabelecida a reprimenda final em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Consoante a previsão do artigo 33, § 3º, bem como o artigo 34, ambos do Código Penal, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena imposta para o delito de resistência qualificada.

Justifico a expiação em regime mais gravoso tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes e reincidência, representada pelos autos dos Processos nº 1500406-48.2021.8.26.0571, nº 1500917-18.2020.8.26.0624 e nº 0005010-69.2018.8.26.0624, conforme se observa da certidão de fls. 51/55.

Trata-se, pois, de motivo suficiente para demonstrar a necessidade de imposição de um regime mais enérgico, o qual se revela necessário para que o réu absorva o caráter punitivo esperado pela lei penal, evitando-se a ocorrência de novas infrações, o que, com a aplicação de um regime mais brando, certamente não ocorrerá.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, prevista no artigo 44 do

Código Penal, porquanto o réu não atende os seus requisitos.

De igual modo, não é possível a concessão de suspensão condicional da pena, disciplinada no artigo 77 do Código Penal.

Por outro lado, reputo ausentes motivos aptos a ensejar a custódia preventiva do acusado, em atenção ao artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual defiro o recurso em liberdade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ JOILSON LEITE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 329, § 1º, do Código Penal e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, ambos os delitos com incidência do artigo 61, inciso I (reincidência), e artigo 65, inciso III, alínea "d" (confissão espontânea), e na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado e 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade. CONFORME FUNDAMENTADO, DEFIRO O APELO EM LIBERDADE.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

O réu está assistido por Defensor nomeado, circunstância que gera a presunção de não dispor de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas, observando a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça às fls. 76/77.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao Advogado que atuou no feito patrocinando os interesses do réu (fl. 59), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Tatui, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA